

1500292-71.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS.

LIBERDADE PROVISÓRIA: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500292-71.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500292-71.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WÉMERSON CAETANO BENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

WÉMERSON CAETANO BENTO foi denunciado por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 11h55min, na Rua Flôr de Lis, 221, Biqueira Caçamba - Chácara Maria Francisca, nesta cidade de Mauá, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo de constatação de fls. 08-4.

Recebida a denúncia, o réu foi citado (fls. 88) e apresentou resposta à acusação (fls. 91-2).

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas. Decretou-se a revelia do réu (fl.118).

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa suscita a nulidade da decisão que decretou a revelia, bem como a nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, reconhecendo-se o tráfico privilegiado, sob regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo da Defensoria Pública, as preliminares levantadas não se sustentam.

A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, destacando-se a falta de requisito objetivo (fls.94-100).

Em relação à revelia, nota-se a ocorrência da preclusão, uma vez que nada foi levantando durante a audiência de instrução debates e julgamento, momento oportuno para referida insurgência.

Além disso, observa-se que o réu foi devidamente intimado para audiência (fl. 117), porém não compareceu e não justificou a ausência, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ao contrário do sustentado pela defesa, a intimação do réu não ocorreu na véspera do ato, mas sim três dias antes. Neste ponto, observa-se a certidão do Sr. Oficial de Justiça:

"[...] dirigi-me ao endereço Viela 18 (entrada ao lado do número 07 da Rua Flor de Lis), na casa ao lado/fundos do imóvel 40A (zero apagado), nesta cidade (a casa foi localizada após orientações de moradoras locais: ao entrar na viela e ao final da escada, manter-se a direita onde haverá outra pequena escada na qual em seu final é possível localizar casa com indicação de número 40A próximo ao local onde fui recebida pelo réu após ser chamado por moradores) em 27 de maio de 2022 às 10:45 horas quando intimei Wémerson Caetano Bento, que assim declarou-se chamar, de todo o teor desta ordem judicial, que aceitou a contrafé oferecida e que deixou de exarar sua assinatura nos termos do item 2, alínea d, do Comunicado Conjunto nº 249/2020 (que regulamenta o Provimento CSM nº 2549/2020), razão pela qual procedo a descrição de forma aparente: pessoa do gênero masculino, em faixa etária jovem, estatura média, fisionomia magra, cutis parda, olhos escuros, cabelos curtos usando boné e tatuagem na bochecha direita" (fl. 117).

Afastam-se, assim, as preliminares suscitadas.

No mérito, procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 12-5), auto de exibição e apreensão (fl. 06), fotografias de fls. 32-5, laudo de constatação (fls. 08-11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 66-8), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogado, em solo policial, o réu admitiu que (sic) "estava no local com o fulcro de vender os entorpecentes, sendo hoje o seu primeiro dia. Que por tais préstimos receberia a importância de cem reais" (fl. 05).

O policial civil Vanderlei, na fase administrativa, historiou que (sic) "em companhia de seu parceiro, ora relacionado como testemunha, dirigiram-se ao local dos fatos, onde existe um ponto conhecido pela mercancia de drogas. Que se posicionaram em local estratégico, de onde podiam observar a entrada da viela, onde podiam observar alguns usuários, os quais entravam na viela um por vez e após breve período, saiam apressadamente do local. Que momento oportuno, e com apoio de outros Policiais desta unidade, promoveram a incursão policial naquela viela, cercando todas as saídas, minimizando as possibilidades de reação de quem quer que seja. Que no momento da incursão uma pessoa que se posicionava no meio da viela, que portava um pequeno estojo de cor azul em uma de suas mãos, saiu em desabalada carreira, sentido viela adentro, vindo justamente em direção do condutor e da testemunha que promoviam a entrada na viela. Que o suspeito jogou o estojo que trazia consigo, entre os barracos ali existente, com a clara intenção de dissimular suas ações, saindo correndo entre os barracos. Que tal pessoa foi identificada como sendo WEMERSON CAETANO BENTO, o qual passou a dizer "perdi senhor! perdi", apontando de imediato o local onde havia jogado o estojo com as drogas em seu interior. Que ao ser questionado acerca dos fatos, o indiciado disse que ali estava vendendo entorpecentes com a finalidade de angariar fundos para custear o sustento de sua família e comprar um botijão de gás. Que ganharia o valor de R\$ 100,00 (cem Reais) e ali permaneceria no período das 08hrs até as 17hrs. Que no interior do estojo que trazia consigo, foram encontradas as drogas ora apreendidas, além da quantia de cento e quinze reais em moeda corrente e em notas diversas" (fl. 03). No mesmo sentido as declarações extrajudiciais do policial civil Wagner (fl. 04).

Em juízo, os policiais civis confirmaram integralmente a dinâmica do ocorrido e confirmaram ter visualizado movimentação típica do tráfico no local do ocorrido, um ponto de venda de entorpecentes. Ao ingressarem na referida viela, visualizaram o réu com uma pochete na mão. Este, por sua vez, correu e dispensou a pochete, mas foi abordado. No estojo encontraram drogas e dinheiro. Informalmente o réu confessou a prática delitiva (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que o depoimento prestado em juízo pelos policiais, além de plenamente coerentes, está em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a Autoridade Policial. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente o réu.

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido em notas diversas, trazem elementos suficientes de que o réu tinha a droga para entrega a terceiros.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado 1/6 acima do mínimo legal, em razão da grande quantidade de drogas apreendida - 105 porções de cocaína (81,9 gramas), 22 porções de maconha (40,6 gramas) e 25 porções de crack (6,4 gramas) - fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta dos agentes (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Na fase intermediária, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não se desconhece que a quantidade do entorpecente, nos termos da Repercussão Geral no ARE nº 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, deve ser ponderada em apenas uma das fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

Todavia, diante das circunstâncias do delito - o réu trazia consigo considerável quantidade e variedade de entorpecentes, em local conhecido como ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas, portanto sem espaço para "iniciantes"; além de não ter comprovado o exercício de atividade lícita - parece-me claro o acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Nota-se, ainda, que o réu já respondeu a processos pela prática de atos infracionais, um deles por crime análogo ao tráfico de drogas, inclusive (fl. 43 e consulta aos procs. 0010522-56.2016 e 0002165-53.2017 no ESAJ). Evidente, portanto, que se dedica às atividades criminosas.

Nessa linha, posiciona-se o e Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA

TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Repita-se que, nesta etapa, não há bis in idem na valoração da quantidade de drogas, já que tal circunstância foi utilizada apenas supletivamente, conjugada com outros vetores do caso concreto, para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...]" (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugênio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema

altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO, REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo para fixar a pena-base em seu patamar mínimo e, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, majorando as penas do embargante para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, e fixar o regime inicial fechado, vencido em parte o E. Des. Ricardo Sale Júnior, que negava provimento ao recurso acusatório, mantendo o redutor e regime semiaberto, aplicados em primeiro grau. Maioria que considera imperativo o afastamento do redutor, pelas circunstâncias em que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi praticado - quantidade e variedade considerável de entorpecentes (16 porções de cocaína, na forma de crack, com massa de 49,7 gramas; e 02 porções de maconha, pesando 41,7 gramas pesos líquidos, cf. laudos de fls. 16/17 ou 53/54 e 89/91), além de dinheiro - circunstâncias concretas que indicam que o apelado já gozava da confiança na cadeia da traficância para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa. Regime inicial de cumprimento de pena fechado imperativo, ante a gravidade concreta do delito praticado, com vistas principalmente à repressão e à prevenção delitiva e resguardo da tutela social, ao menos no início do cumprimento da pena privativa de liberdade, tal como decidiu a douta Turma Julgadora, por maioria de votos. Embargos infringentes rejeitados. (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0000079-92.2017.8.26.0580; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 19/05/2021; Data de Registro: 19/05/2021 - grifo nosso).

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas - Confissão do acusado - Falas dos policiais firmes e coerentes - Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Traficância comprovada - Condenação era de rigor - Causa de aumento comprovada - Penas bem

dosadas - Privilégio do art. 33, § 4º, da LD - Não cabimento - Regime inicial fechado mantido - Substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Impossibilidade - Sentença mantida - Recurso defensivo desprovido. [...] No presente caso, o réu possuía quase 100 porções de drogas variadas, dentre elas, cocaína e crack, entorpecentes de elevado potencial lesivo, demonstrando seu envolvimento na atividade criminosa. Ademais, não comprovou ocupação lícita, e confirmou que já atuava na venda ilegal havia um mês. Portanto, à luz das peculiaridades do caso em tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável que as circunstâncias concretas do delito praticado impedem a aplicação do §4º, do artigo 33, da lei 11.343/06. Frise-se que mencionado parágrafo 4º emprega o termo "poderão", o que seguramente indica não ser obrigatória a redução. [...] (TJSP; Apelação Criminal 1501589-14.2020.8.26.0628; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/05/2022; Data de Registro: 16/05/2022 - grifo nosso).

Define-se, assim, a condenação em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do acusado.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97,256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WÉMERSON CAETANO BENTO, qualificado nos autos, a cumprir pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 583 dias-multa, no patamar mínimo, por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Faculta-se ao réu o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se para a destruição da contraprova das drogas e do estojo apreendido (fls. 06). Além disso, decreto a perda dos valores (fl. 65), em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA